

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาย ไพโรจน์ เต็งหิรัญ กับพวก  
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 831/2539  
พัน ตำรวจ ตรี สนิท มาลากิจสกุล กับ  
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 219, มาตรา 420, มาตรา 438

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142, มาตรา 183 วรรคสอง, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

จำเลยให้การต่อสู้เพียงว่าตามรายงานประจำวันกำหนดให้จำเลยปฏิบัติตามข้อตกลงภายในวันที่30เมษายน2534โจทก์นำคดีมาฟ้องก่อนกำหนดจึงไม่มีอำนาจฟ้อง ดังนั้นข้อที่จำเลยฎีกาว่ารายงานประจำวันเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความทำให้มูลหนี้ละเมิดระงับเป็นข้อที่จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ไว้จึงไม่เป็นประเด็นที่ต้องวินิจฉัย แม้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยมาก็เป็นการวินิจฉัยโดยมิชอบถือว่าเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา249วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ตามรายงานประจำวันจำเลยรับว่าจะดำเนินการป้องกันความเสียหายแก่ที่ดินของโจทก์โดยจะทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2534และรับว่าจะไม่ขุดดินในแนวสโลปอีกแต่หลังจากทำบันทึกตามรายงานประจำวันดังกล่าวเมื่อวันที่24มิถุนายน2531แล้วจำเลยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในรายงานประจำวันดังกล่าว โดยยังกลับขุดดินทำให้ที่ดินของโจทก์เสียหายอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ขึ้นอีก โจทก์จึงฟ้องจำเลยได้ ตามรายงานประจำวันระบุว่าจำเลยยอมรับผิดชอบในความเสียหายในเนื้อที่ดินของฝ่ายโจทก์และผู้เสียหายรายอื่นทุกแปลงและจะกระทำการ

ต่างๆเพื่อป้องกันการเลื่อนไหลของดินฉะนั้นที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลย  
ดำเนินการนำดินมาถมและทำคันดินก็เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อที่ดินของ  
ฝ่ายโจทก์อีกถือได้ว่าตรงตามความประสงค์ของคู่กรณีในรายงานประจำวันดังกล่าว  
จึงเป็นวิธีการที่ทำให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหมดสิ้นไปและป้องกันความเสียหายที่จะ  
เกิดขึ้นอีกที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แล้ว

---

โจทก์ทั้งสามฟ้องว่า โจทก์ทั้งสามเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 1461  
จำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดินหรือเป็นเจ้าของบ่อดินซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของโจทก์ทั้ง  
สามด้านทิศตะวันตกกจำเลยทั้งสองประกอบธุรกิจถมดิน ทราบ ลูกจ้าง เมื่อวันที่  
18มิถุนายน 2533 โจทก์ทั้งสามพบว่าที่ดินของโจทก์ทั้งสามทางทิศตะวันตกและทิศ  
ใต้ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินหรือบ่อดินของจำเลยทั้งสองได้แตกร้าวและพังทลายลงเนื่องจาก  
การขุดหน้าดินในที่ดินหรือบ่อดินของจำเลยทั้งสอง และจำเลยทั้งสองยังได้รุกล้ำเข้า  
ทำการขุดดินในที่ดินของโจทก์ทั้งสามประมาณ 2 งาน ไปขายด้วยเป็นเหตุให้ที่ดิน  
ของโจทก์ทั้งสามพังทลายลงติดต่อกันเป็นแนวยาวตลอดแนวเขตที่ดินของโจทก์ทั้ง  
สามต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2533โจทก์ทั้งสามได้ร่วมกับผู้เสียหายรายอื่น ๆ ไป  
แจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยทั้งสองที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอลำลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจำเลยที่ 1 มาเจรจาขอรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในเนื้อที่ดินของผู้  
เสียหายทุกแปลง และตกลงทำแนวป้องกันการพังทลายและเลื่อนไหลของดิน หลัง  
จากทำบันทึกข้อตกลงแล้วจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามโดยจำเลยทั้งสองยังคงดำเนิน  
การขุดดินเรื่อยไปและรุกล้ำเข้ามาขุดดินในที่ดินของโจทก์ทั้งสามมากขึ้นประมาณ 5  
งานเป็นเหตุให้ที่ดินของโจทก์ทั้งสามได้รับความเสียหายพังทลาย ขอให้บังคับจำเลย  
ทั้งสองก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดิน โดยให้ใช้เสาคอนกรีตเสริมเหล็กอัด

แรงรูปตัวไอขนาด 0.30 X 0.30 X 15 เมตร ตอกลึกลงในที่ดินเป็นฐานรากใต้ดินของ  
เขื่อนทุกระยะ 1 เมตร และใช้แผงกันดินคอนกรีตหนา 0.10 เมตรกันลึกตั้งแต่ระดับ  
กันบ่อถึงแนวพื้นที่ดินปกติ และใช้สมอยึดตัวเขื่อนทุกระยะ 3 เมตร และให้จำเลย  
ทั้งสองเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังเขื่อนลงในที่ดินหรือบ่อดินของจำเลยทั้งสอง  
แปลงที่ติดอยู่ทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ของที่ดินโจทก์ทั้งสามตำบลคลองซอยที่  
8 (ฝั่งตะวันตก) อำเภอมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ในระยะแนวขีดแนวที่ดินของโจทก์  
ทั้งสามเป็นแนวตลอดความยาวของที่ดินที่พังทลายเป็นความยาว 65 เมตร หนึ่งด้าน  
และเป็นความยาว 30 เมตร อีกหนึ่งด้าน และให้ปรับถมที่ดินของโจทก์ทั้งสามแปลง  
โฉนดเลขที่ 1461 ตำบลคลองซอยที่ 8 (ฝั่งตะวันตก) อำเภอมีนบุรี  
กรุงเทพมหานคร ตลอดแนวที่พังทลายและที่หายไปให้เสมอแนวพื้นที่ดินทั่วไปของ  
โจทก์ทั้งสาม หากจำเลยทั้งสองไม่ยอมปฏิบัติ ขอให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ  
โดยให้จำเลยทั้งสองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย กับให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเสียหายเป็นเงิน  
เดือนละ 5,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะสร้างเขื่อนและ  
ปรับถมที่ดินของโจทก์ทั้งสามให้แล้วเสร็จหมายเลข 3 จำเลยที่ 1 เป็นเพียงตัวแทน  
ผู้รับผิดชอบไปเจรจาเท่านั้น จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 โจทก์ทั้งสามไม่ได้  
เสียหาย ถ้ามีก็เป็นเพียงนำดินมาปรับถมในที่ดินของโจทก์ทั้งสามไม่จำเป็นต้องทำ  
เขื่อนตามคำฟ้องโจทก์ทั้งสามเพราะที่ดินของโจทก์ทั้งสามกับบ่อดินข้างเคียงมีถนน  
คันดินกั้นอยู่เป็นการป้องกันความเสียหายอยู่แล้ว โจทก์ทั้งสามฟ้องคดีก่อนที่จะครบ  
กำหนดระยะเวลาตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 ซึ่งกำหนดให้จำเลยปฏิบัติตาม  
เอกสารดังกล่าวภายในวันที่ 30 เมษายน 2534 โจทก์ทั้งสามไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้  
ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนกับจำเลยที่ 1 เมื่อจำเลยที่ 2  
ซื้อที่ดินมาก็เห็นว่าที่ดินของโจทก์ทั้งสามถูกขุดหน้าดินไปขายบ้างแล้ว และจำเลยที่  
2 ซื้อที่ดินหลังจากที่โจทก์ทั้งสามอ้างว่าพบเหตุที่จำเลยทั้งสองกระทำละเมิดเมื่อ

วันที่ 18 มิถุนายน 2533 แล้ว นอกจากนี้จำเลยที่ 2 ได้ทำการป้องกันความเสียหาย โดยทำคันดินกันแล้ว ความเสียหายในที่ดินของโจทก์ทั้งสามเกิดจากฝนตกน้ำกัดเซาะ ไม่ได้เกิดจากการกระทำของจำเลยที่ 2 แต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองนำดินมาถมที่ดินของโจทก์ทั้งสามในส่วนที่ได้รับ ความเสียหายจากแบบพิมพ์เขียวเอกสารหมายเลข 14 เป็นเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา ปริมาณของดินที่นำมาถม 17,368 ลูกบาศก์เมตร เมื่อถมดินเสร็จแล้วให้ ทำคันดินกว้าง 3 เมตร ยาว 391 เมตร ในที่ดินของจำเลยและเมื่อ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า บันทึกข้อตกลงความตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 จำเลยที่ 1 เป็นเพียงตัวแทนผู้รับผิดชอบไปเจรจาเท่านั้น จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ จำเลยที่ 2 โจทก์ทั้งสามไม่ได้เสียหาย ถ้ามีก็เป็นเพียงนำดินมาปรับถมในที่ดินของ โจทก์ทั้งสามเพราะที่ดินของโจทก์ทั้งสามกับบ่อดินข้างเคียงมีถนนคันดินกันอยู่ เป็นการป้องกันความเสียหายอยู่แล้ว โจทก์ทั้งสามฟ้องคดีก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 ซึ่งกำหนดให้จำเลยปฏิบัติตามเอกสารดังกล่าว ภายในวันที่ 30 เมษายน 2534 โจทก์ทั้งสามไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนกับจำเลยที่ 1 เมื่อจำเลยที่ 2 ซื้อที่ดินมาก็เห็นว่าที่ดินของโจทก์ทั้งสามถูกขุดหน้าดินไปขายบ้างแล้ว และจำเลยที่ 2 ซื้อที่ดินหลังจากที่โจทก์ทั้งสามอ้างว่าพบเหตุที่จำเลยทั้งสองกระทำละเมิดเมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน 2533 แล้ว นอกจากนี้จำเลยที่ 2 ได้ทำการป้องกันความเสียหาย โดยทำคันดินกันแล้วความเสียหายในที่ดินของโจทก์ทั้งสามเกิดจากฝนตกน้ำกัดเซาะ ไม่ได้เกิดจากการกระทำของจำเลยที่ 2 แต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองนำดินมาถมที่ดินของโจทก์ทั้งสามในส่วนที่ ได้รับ ความเสียหายจากแบบพิมพ์เขียวเอกสารหมายเลข 14 เป็นเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 11

ตารางว่า ปริมาณของดินที่นำมาถม 17,368 ลูกบาศก์เมตร เมื่อถมดินเสร็จแล้วให้  
ทำคันดินกว้าง 3 เมตร ยาว 391 เมตร ในที่ดินของจำเลยและเมื่อทำคันดินเสร็จ  
แล้วให้ทำเชื่อมกันดินลดหลั่นเป็นขั้นบันไดจากที่ดินของโจทก์ทั้งสามมายังที่ดินของ  
จำเลย จากปากบ่อดินถึงกันบ่อดิน เชื่อมต้องตอกเสาเข็มไม้เป็นตัวยึด และต้องทำ  
ยาว 1,084 เมตร หากจำเลยทั้งสองไม่ทำก็ให้บุคคลภายนอกทำแทนโดยให้จำเลยทั้ง  
สองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายเดือนละ  
4,000 บาท แต่โจทก์ทั้งสามนับแต่วันฟ้องวันที่ (วันที่ 9 มกราคม 2534) จนกว่า  
จำเลยทั้งสองจะดำเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวเสร็จสิ้น

จำเลย ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองเป็นหุ้นส่วนกัน สำหรับฎีกาของจำเลยทั้งสอง  
ว่า รายงานประจำวันเอกสารหมายเลข 4 เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความมูลหนี้  
ละเมิดระงับไปแล้ว และตามรายงานประจำวันเอกสารหมายเลข 4 กำหนดให้จำเลยทั้ง  
สองปฏิบัติตามข้อตกลงภายในวันที่ 30 เมษายน 2534 โจทก์ทั้งสามนำคดีมาฟ้อง  
ก่อนกำหนดจึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น ในข้อนี้จำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้แต่เพียงว่าโจทก์ทั้ง  
สามไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะได้ฟ้องก่อนวันที่ 30 เมษายน 2534 อันเป็นกำหนดเวลา  
ตามรายงานประจำวันเอกสารหมายเลข 4 เท่านั้นจะนั้นข้อที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า  
รายงานประจำวันเอกสาร หมายเลข 4 เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความทำให้มูลหนี้ละเมิด  
ระงับเป็นข้อที่จำเลยทั้งสองมิได้ให้การต่อสู้ไว้ จึงไม่เป็นประเด็นที่ต้องวินิจฉัย แม้  
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยมาก็เป็นการวินิจฉัยโดยมิชอบ ถือว่าเป็นข้อที่  
มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามฎีกาตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับ  
วินิจฉัยให้ ส่วนที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า โจทก์ทั้งสามนำคดีมาฟ้องก่อนกำหนดเวลา  
ตามรายงานประจำวันเอกสารหมาย จ.4 จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น ตามรายงานประจำ  
วันเอกสารหมาย จ.4 จำเลยที่ 1 รับว่าจะดำเนินการป้องกันความเสียหายแก่ที่ดินของ  
โจทก์ทั้งสามโดยจะทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2534 และรับว่าจะไม่ขุด  
ดินในแนวสโลปอีก ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์ทั้งสามนำสืบว่าจำเลยทั้งสองไม่  
ปฏิบัติตามข้อตกลงในรายงานประจำวันเอกสารหมาย จ.4 โดยยังกลับขุดดินทำให้  
ที่ดินของโจทก์ทั้งสามเสียหายอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสามขึ้นอีก ฉะนั้นโจทก์  
ทั้งสามจึงฟ้องจำเลยทั้งสองได้ จำเลยทั้งสองฎีกาข้อสุดท้ายว่าศาลล่างทั้งสองให้  
จำเลยทั้งสองถมดินในที่ดินของโจทก์ทั้งสามในส่วนที่ได้รับความเสียหายไม่ถูกต้อง  
เพราะวิธีการตามข้อตกลงในรายงานประจำวันเอกสารหมาย จ.4 สามารถป้องกัน  
ความเสียหายได้อยู่แล้ว และค่าเสียหายเดือนละ 4,000 บาท สูงเกินไปเห็นว่า ตาม  
รายงานประจำวันเอกสารหมาย จ.4 จำเลยทั้งสองยอมรับผิดชอบในความเสียหายใน  
เนื้อที่ดินของฝ่ายโจทก์ทั้งสามและผู้เสียหายรายอื่นทุกแปลง และจะกระทำการต่าง  
ๆ เพื่อป้องกันการเลื่อนไหลของดิน ฉะนั้น ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยทั้งสอง  
ดำเนินการนำดินมาถมและทำคันดินก็เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อที่ดินของ  
ฝ่ายโจทก์ทั้งสามอีก ถือได้ว่าตรงตามความประสงค์ของคู่กรณีในรายงานประจำวัน  
เอกสารหมาย จ.4 จึงเป็นวิธีการที่ทำให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหมดสิ้นไปและป้องกัน  
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอีกที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แล้ว ส่วนค่าเสียหายเดือนละ  
4,000 บาท นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าการขุดดินของจำเลยทั้งสองเป็นเหตุ  
ให้ฝ่ายโจทก์ทั้งสามไม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามปกติ จำเลยทั้งสองก็ต้อง  
รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้ฝ่ายโจทก์ทั้งสามซึ่งเมื่อพิจารณาพฤติการณ์และความร้าย  
แรงในคดีนี้แล้ว เห็นว่าที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าเสียหายให้ฝ่ายโจทก์ทั้งสามเดือน  
ละ 4,000 บาทเหมาะสมแล้ว

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ